

1505474-56.2021.8.26.0125

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Fredison Capeline

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DO NARCOTRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA NULA. 1. SUBMETE-SE ÀS PENAS DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 QUEM, POR VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, GUARDA OU TRAZ CONSIGO, PARA USO PESSOAL, DROGAS SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. 2. NÃO HÁ FALAR EM ATIPICIDADE DO DELITO, POR HAVER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Dr. João Adolfo Stein, 171, Capivari-SP - cep 13360-067

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505474-56.2021.8.26.0125 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505474-56.2021.8.26.0125

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Fato Atípico

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3078077/2021 - DEL.POL.CAPIVARI, 20381833 - DEL.POL.CAPIVARI

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RODRIGO BARBOSA FRANÇA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fredison Capeline

Vistos.

Relatório dispensado na forma do art. 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

I - FUNDAMENTAÇÃO:

A ação procede.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 01/02; Auto de Exibição e Apreensão de fls. 03, Laudo Pericial de fls. 16/18, bem como pela prova oral.

Autoria é certa.

A testemunha Fernando Sebuske, Guarda Municipal, declarou que no dia dos fatos estava ocorrendo uma operação da Polícia Civil e na posse do réu foram encontradas duas porções contendo cocaína.

A testemunha Marcelo de Jesus Aparecido Monaro, Policial Civil, narrou fatos semelhantes aos indicados pela testemunha anterior.

Em Juízo, réu ausente, mesmo intimado ao ato, cuja revelia seu interrogatório, assim como a coleta de sua versão. No entanto, perante a autoridade policial, confessou a posse dos entorpecentes para seu uso pessoal.

Com razão, pois, o Órgão acusatório.

Registro a validade do depoimento dos policiais ou agentes estatais, conforma larga jurisprudência acerca dessa situação.

O fato imputado ao réu é típico, ilícito e culpável, não deixando de constituir crime na ordem nacional, que apenas retirou a pena corporal do preceito secundário (despenalização).

Sobre a tipicidade penal do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela sua incidência, reconhecendo se tratar de crime, inclusive com inviabilidade de aplicação do princípio da insignificância, conforme ARE 728688 AgR/DF: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. POSSE DE ENTORPECENTES. USO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO AI N.º 747.522. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos requisitos estabelecidos na legislação infraconstitucional, posto controversia de natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do AI n.º 747.522-RG, Relator Min. Cezar Peluso, DJe de 25/9/2009. 2. A aplicação do princípio da insignificância exige que a conduta seja minimamente ofensiva, que o grau de reprovabilidade seja ínfimo, que a lesão jurídica seja inexpressiva e, ainda, que esteja presente a ausência de periculosidade do agente. In casu, não há elementos suficientes a fim de se apreciar o preenchimento de todos os pressupostos hábeis à aplicação do aludido princípio, a fim de trancar a ação penal. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE. NULA A DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO A INVOCÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RISCO POTENCIAL DO DELITO PARA A SOCIEDADE. USUÁRIO QUE ALIMENTA O COMÉRCIO DA DROGA E PERMITE A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DO NARCOTRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA NULA. 1. SUBMETE-SE ÀS PENAS DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 QUEM, POR VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, GUARDA OU TRAZ CONSIGO, PARA USO PESSOAL, DROGAS SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. 2. NÃO HÁ FALAR EM ATIPICIDADE DO DELITO, POR HAVER POUCA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, JÁ QUE O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 É DE PERIGO ABSTRATO PARA A SAÚDE PÚBLICA - POR SER CAPAZ DE GERAR DEPENDÊNCIA FÍSICO-QUÍMICA -, DE MANEIRA QUE O LEGISLADOR ENTENDEU POR BEM MANTER A TIPICIDADE DA CONDUTA, AINDA QUE SEM APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE. 3. 'NUMA SOCIEDADE QUE CRIMINALIZA PSICOATIVOS E ASSOCIA EXPERIÊNCIAS DE ALUCINÓGENOS À MARGINALIDADE, O CONSUMO DE DROGAS PROVOCA UMA SÉRIA QUESTÃO ÉTICA: QUEM CONSOME É TÃO RESPONSÁVEL POR CRIMES QUANTO QUEM VENDE. AO CHEIRAR UMA CARREIRA DE COCAÍNA, O NARIZ DO CAFUNGADOR ESTÁ CHEIRANDO AUTOMATICAMENTE UMA CARREIRA DE MORTES, CONSCIENTE DA TRAJETÓRIA DO PÓ. PARA CHEGAR AO NARIZ, A DROGA PASSOU ANTES PELAS MÃOS DE CRIMINOSOS. FOI REGADA A SANGUE'. (...) É PROPOSITAL [NO FILME "O DONO DA NOITE", DE PAUL SCHRADER] A REPETIÇÃO RITUALÍSTICA DE CENAS QUE MOSTRAM A ROTINA DO ENTREGADOR, ENCERRADO NUMA LIMUSINE PRETA E FÚNEBRE. NESSE CONTEXTO, A DROGA NÃO CUMPRE MAIS A FUNÇÃO SOCIAL DAS ANTIGAS CULTURAS. ELA É APENAS UM VEÍCULO DE ALIENAÇÃO E AUTODESTRUÇÃO". (FILHO, ANTÔNIO GONÇALVES. A PALAVRA NÁUFRAGA - ENSAIOS SOBRE CINEMA. SÃO PAULO: COSAC SC NAIFY, 2001. P. 259-60 - NÃO GRIFADO NO ORIGINAL). 4. PRECEDENTE: 'ACÓRDÃO N. 560684, 20100110754213APJ, RELATOR JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, 2A TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JULGADO EM 17/01/2012, DJ 25/01/2012 P. 173'. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA COM VISTAS AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO." 4. Agravo regimental DESPROVIDO." [grifei]

Além disso, não se sustenta a tese acerca da atipicidade pelo princípio da insignificância.

Com efeito, em que pese o esforço da defesa, a ofensividade da conduta e a lesão ao bem juridicamente tutelado, qual seja, a saúde pública e não a saúde individual do usuário, são inequívocas, até mesmo porque, conforme entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência, o delito de porte de drogas para consumo pessoal tem natureza de crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a prova concreta de dano

à saúde pública. Cabe, portanto, reconhecer que a criminalização do uso de entorpecentes se justifica em face da função preventiva geral do direito penal, com o claro intuito de desestimular a prática do uso e do tráfico de drogas. Nesse sentido, anoto o quanto já decidido por esta 16ª Câmara de Direito Criminal: "Posse de drogas para consumo pessoal. Preliminar de nulidade em virtude de ter o paciente sido interrogado nos termos do procedimento da Lei de Drogas. Ausência de irregularidade. Procedimento especial que predomina sobre o ordinário. Materialidade e autoria confirmadas pela prova amealhada nos autos. Inexistência de inconstitucionalidade no tipo do art. 28 da Lei 11.363/2006, por ausência de violação do princípio da alteridade. Pena. Extinção pelo cumprimento devido à aplicação da detração (art. 42 do CP). Apelo parcialmente provido para esse fim." (TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal Apelação n. 0002009-72.2012.8.26.0564 Des. Rel. Otávio de Almeida Toledo Julgado em 04/02/2014 - Data de registro: 06/02/2014).

Sem ignorar isolada decisão do E. Supremo Tribunal Federal em sentido contrário [cf. HC 110.475, rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.3.2012], a pequena quantidade de droga apreendida com o agente para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atipicidade da conduta com a aplicação do princípio da insignificância, pois, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, a punição do agente se justifica pelo perigo social que a conduta representa para a saúde e incolumidade públicas. Frise-se que o legislador "optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas" [STF - HC 102.940, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª T, DJE de 6-4-2011]. E não se perca de vista que "o objeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde pública, e não apenas a saúde do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes" [STJ - RHC 35.920, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.5.2014].

Assim sendo, provada a materialidade e autoria, passo a aplicar-lhe a pena prevista para sua conduta.

Inviável a aplicação da advertência ao réu, porquanto o réu ostenta registros de ordem criminal, conquanto tecnicamente primário conforme ficha de fl.10, tenho que o fato de responder a processo criminal por tráfico de drogas demonstra seu intento de se enveredar e fazer do crime seu meio de vida, o que deve ser repellido pelo Estado na busca da paz social, de modo que não se revela adequada e suficiente a imposição da medida mais branca (qual seja, a advertência) por não ter a utilidade que dela se espera no sentido de incutir no réu os malefícios do uso de droga.

II - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar o réu RODRIGO BARBOSA FRANÇA, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos do §§ 3º e 4º do art. 28 da Lei 11.343/2006, incursos o réu nas sanções do artigo 28 da Lei de Drogas.

Transitado em julgado, promova-se o que segue:

- i) lance-se o nome dos réus no "rol dos culpados" e oficie-se ao T.R.E.;
- ii) autorizo a destruição da droga apreendida, caso ainda não promovido;
- iii) expeça-se certidão de honorários pelo convênio firmado entre OAB-SP/DPE, se o caso.

P.I.C.

Capivari, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA